

1501116-42.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... hierárquica importante no escalão do tráfico. O Réu é conhecido dentro da favela como alguém com poder no meio do tráfico. Não se recorda da quantidade de drogas, mas era Cocaína e Skank. O réu disse que levaria a droga para uma favela em Itanhaém. As drogas estavam embaladas para mercancia. Também havia dinheiro em espécie, não se recordando da quantia. O aparelho celular ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501116-42.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501116-42.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077988/2022 - 03º D.P. CUBATÃO, 23757751 - 03º D.P. CUBATÃO, 155/22/231 - 03º D.P. CUBATÃO, 2077988 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMÍLIO LEONARDO PASSOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

I - RELATÓRIO

EMÍLIO LEONARDO PASSOS PEREIRA, vulgo "Léo" foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 21 de março de 2022, por volta das 17h45, na Avenida Joaquim Jorge Peralta, Jardim Casqueiro, Cubatão, EMÍLIO LEONARDO PASSOS PEREIRA, vulgo "Leo", qualificado a fls. 14, transportava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, cocaína e skunk, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 06/07, auto de constatação preliminar de fls. 08 e laudo definitivo das drogas

de fls. 119/121. Segundo o apurado, policiais civis, durante atuação de campo, em uma viatura descaracterizada, avistaram um veículo VW/Fox, cor vermelho, placas FQW6I80, saindo de um local popularmente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Deram, então, alerta visual e sonoro de abordagem, momento em que o denunciado tentou empreender em fuga, tendo sido alcançado. No ato da abordagem, os policiais visualizaram, no interior do automóvel, sobre o banco do passageiro, um saco plástico, contendo, em seu interior, 227 microtubos com cocaína (peso líquido - 51,9g), 84 invólucros de skunk (peso líquido - 20,8g), R\$ 70,00 em espécie, um smartwatch, marca Apple, e um aparelho celular, marca Samsung. Indagado, confessou, informalmente, que estava transportando os entorpecentes supramencionados para o Município de Itanhaém, com o fim de abastecer uma biqueira, no bairro Suarão. A razoável quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, os testemunhos dos policiais e a confissão informal do denunciado, demonstram que praticava tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 135/139).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 221).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a nulidade do relatório policial apresentado em fls. 230-238.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de

prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08), termo de depoimento (fls. 10/13, 84/88), relatório final (fls. 83, 94/95, 117/118), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciaria.

Vejamos:

Em solo policial, o condutor e testemunha LIDIO GODOY DE CARVALHO disse que “Encontrava-se junto ao policial testemunha em uma viatura descaracterizada realizando diligências investigativas diversas nas adjacências do bairro Jardim Casqueiro, nesta urbe de Cubatão/SP, instante em que visualizaram um veículo VW/Fox vermelho de placas FQW6I80 saindo de um local bastante conhecido como ponto de tráfico. Diante da fundada suspeita, os policiais se aproximaram emitindo sinalização visual e sonora com a viatura, bem como verbalizaram com o intuito de efetuar a abordagem, porém o condutor do veículo acelerou e tentou empreender fuga. Consequentemente, os policiais passaram a persegui-lo por um percurso de aproximadamente 500 metros e lograram êxito em pará-lo e abordá-lo. Efetuada a abordagem com cautela, os policiais reconheceram de imediato o condutor do veículo como sendo EMILIO LEONARDO PASSOS PEREIRA (vulgo “LEO”), tratando-se de um indivíduo já conhecido nos meios policiais como envolvido em atividades relacionadas à traficância neste município de Cubatão/SP. No ato da abordagem, os policiais visualizaram um saco plástico sobre o banco frontal do passageiro do veículo e constataram que este continha uma quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, consistindo em 277 eppendorffs repletos de pó branco aparentando ser cocaína e 84 invólucros de erva aparentando ser “skunk”. No interior do veículo também foram localizados R\$ 70,00 em espécie, um smartwatch da marca Apple e um aparelho celular da marca Samsung, todos de propriedade de EMILIO. Indagado acerca dos entorpecentes, EMILIO relatou informalmente aos policiais que os transportava para o município de Itanhaém com o intuito de abastecer uma “biqueira” no bairro Suarão, porém não esclareceu a procedência das substâncias. Em relação ao veículo VW/ Fox, EMILIO esclareceu que o adquiriu há aproximadamente cinco meses, que deu um Fiat/Uno que era de sua propriedade com forma de pagamento e que pagou o valor remanescente em dinheiro, porém ainda não formalizou a transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito. Diante dos fatos, os policiais conduziram e apresentaram EMILIO junto ao 3º Distrito Policial de Cubatão, onde também apresentaram o veículo, as substâncias entorpecentes e os demais objetos encontrados em sua posse para que as providências legais de Polícia Judiciária fossem tomadas” (fls. 10/11).

Em Juízo, disse que se recorda dos fatos. Estavam em viatura descaracterizada no local, que é conhecido como ponto de tráfico. Um veículo saiu do local e resolveram acompanhá-lo. Viram que era o Réu, conhecido nos meios policiais. Deram sinal luminoso e sonoro, quando o Réu acelerou ainda mais e foram obrigado a fechá-lo por 3 (três) vezes. O Réu, então abordado, disse que “estava com alguns B.O's” no carro. Apreenderam as drogas e o celular. Após autorização judicial foi realizado a quebra do sigilo e comprovaram que o Réu desempenha função hierárquica importante

no escalão do tráfico. O Réu é conhecido dentro da favela como alguém com poder no meio do tráfico. Não se recorda da quantidade de drogas, mas era Cocaína e Skank. O réu disse que levaria a droga para uma favela em Itanhaém. As drogas estavam embaladas para mercancia. Também havia dinheiro em espécie, não se recordando da quantia. O aparelho celular era do Réu. O réu encontrava-se sozinho no automóvel. Em solo policial, a testemunha FABIO VIEIRA MENDES disse que "Encontrava-se junto ao policial condutor em uma viatura descaracterizada realizando diligências investigativas diversas nas adjacências do bairro Jardim Casqueiro, nesta urbe de Cubatão/SP, instante em que visualizaram um veículo VW/Fox vermelho de placas FQW6I80 saindo de um local bastante conhecido como ponto de tráfico. Diante da fundada suspeita, os policiais se aproximaram emitindo sinalização visual e sonora com a viatura, bem como verbalizaram com o intuito de efetuar a abordagem, porém o condutor do veículo acelerou e tentou empreender fuga. Consequentemente, os policiais passaram a persegui-lo por um percurso de aproximadamente 500 metros e lograram êxito em pará-lo e abordá-lo. Efetuada a abordagem com cautela, os policiais reconheceram de imediato o condutor do veículo como sendo EMILIO LEONARDO PASSOS PEREIRA (vulgo "LEO"), tratando-se de um indivíduo já conhecido nos meios policiais como envolvido em atividades relacionadas à traficância neste município de Cubatão/SP. No ato da abordagem, os policiais visualizaram um saco plástico sobre o banco frontal do passageiro do veículo e constataram que este continha uma quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, consistindo em 277 eppendorffs repletos de pó branco aparentando ser cocaína e 84 invólucros de erva aparentando ser "skunk". No interior do veículo também foram localizados R\$ 70,00 em espécie, um smartwatch da marca Apple e um aparelho celular da marca Samsung, todos de propriedade de EMILIO. Indagado acerca dos entorpecentes, EMILIO relatou informalmente aos policiais que os transportava para o município de Itanhaém com o intuito de abastecer uma "biqueira" no bairro Suarão, porém não esclareceu a procedência das substâncias. Em relação ao veículo VW/ Fox, EMILIO esclareceu que o adquiriu há aproximadamente cinco meses, que deu um Fiat/Uno que era de sua propriedade com forma de pagamento e que pagou o valor remanescente em dinheiro, porém ainda não formalizou a transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito" (fls. 12/13).

Em Juízo, reiterou a versão apresentada em solo policial e corroborou a narrativa empregada por seu colega, sob os auspícios do contraditório. Após a abordagem policial visualizaram uma sacola preta contendo cocaína e skank. O Réu confessou informalmente o transporte da droga para o Bairro Suarão, em Itanhaém, para uma "biqueira de sua propriedade".

Em solo policial, o acusado EMILIO LEONARDO PASSOS PEREIRA resguardou o seu direito de permanecer em silêncio e desejou se manifestar acerca dos fatos apenas em juízo. Sua genitora foi devidamente comunicada e se encontra ciente acerca das circunstâncias de sua prisão e do local onde se encontra (fls. 14).

Interrogado em Juízo, disse que os policiais pegaram seu aparelho celular e começaram a mexer seu aparelho. As drogas foram plantadas em seu automóvel, pois não havia nada. Somente soube a quantidade de drogas na audiência de custódia. Não estava com nada no automóvel. Foi perseguição. Quis permanecer em silêncio em relação às demais perguntas do Juízo, referentes aos contatos telefônicos e a apreensão de seu celular. O smartwatch da apple, celular e dinheiro eram de sua propriedade. Não estava indo para Itanhaém. Não conhece os policiais que o prenderam. Nunca foi abordado por esses policiais. Foi apenas uma vez na delegacia quando seu pai faleceu.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, pois a versão apresentada pelo Réu não encontra eco no manancial probatório, quedando-se isolada, porque quimérica. Cediço que armazenamento de dados da vida privada, íntima, familiar e financeira da pessoa – o seu vasculhamento implica violação do direito à intimidade (artigo 5º, inciso X, da CF) e até mesmo aos direitos da personalidade do preso. Ademais, o artigo 3º da Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, assegura ao usuário desse serviço "à inviolabilidade ao segredo

de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas", e o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.965/14 (conhecida como Marco Civil da Internet), que regulamenta o uso da internet no Brasil, assegura aos seus usuários o direito "a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial".

A esse propósito, colaciona-se trecho do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do Resp 1.782.386, julgado pela 5ª Turma do STJ em 15/12/2020: "A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel". E, a título de exemplos, cita-se algumas decisões que adotaram esse posicionamento: HC. 372.762/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 16/10/2017; RHC 79.452/RR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 01/09/2017; HC 588.135/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14/09/2020; RHC 120.726/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/02/2020; AgRg no RHC 120.172/SP, Rel. Minis. Nefi Cordeiro, 6ª turma, DJe 08/06/2020 e AgRg no HC 516.857/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª turma, DJe 18/5/2020.

Entretanto, no caso em testilha, inexistente qualquer elemento, sequer suasório, no sentido de que o aparelho celular do Réu foi acessado pelos policiais antes da decisão judicial autorizativa (fls. 67-71), ao revés do que sustenta a combativa defesa. Portanto, a cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) mantém-se incólume, máxime em não se logrando dissuadir o relatório apresentado em fls. 230-238, ônus que competia à defesa (art. 156 do CPP).

Ao entender deste juízo, legítima a apreensão do celular, na forma do art. 6º, incs. II e III do CPP, pois dele, em tese, poderia ser extraído elementos de informação sobre a conduta perpetrada.

Conforme "relatório de análise de extração de aparelho celular" (RDO 155/2022), coligido em fls. 230-238, denota-se, estreme de dúvidas, que o Réu Emilio dedicava-se à narcotraficância com habitualidade.

Ora, as vultosas quantidades de drogas comercializadas e os demais elementos extraídos da moldura fática subjacente (vide os prints de troca de mensagens em fls. 232 e as imagens de balanças contendo drogas em fls. 233, por exemplo) demonstram a dedicação de Emilio à mercancia espúria.

Não obstante a isso, a conversa com o interlocutor nomeado "Zé Aldo" (fls. 234-235) demonstra a existência de certo vínculo com o malsinado "Primeiro Comando da Capital", eis que o Réu menciona a necessidade de autorização dos Tribunais do Crime para o comércio das drogas na Vila Esperança. Destarte, "fica evidenciado nesta conversa que o indiciado Leonardo é pertencente ao crime organizado, devido que a pessoa de 'Ze Aldo', comerciante precisa entrar em contato com Leonardo para que o problema seja levado para a 'Disciplina'" (fl. 234).

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento

dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perlustra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficiente para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que o acusado, de forma deliberada, guardava, transportava e tinha em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado (mais precisamente em Itanhaém, além da distribuição local, no município de Cubatão, conforme fls. 230-238), pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas uma das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de uma investigação policial já instaurada há meses. Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autora do acusado em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Adiante que, no caso em análise, é inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque o objetivo do aludido dispositivo de lei é privilegiar a figura comumente denominada por pequeno traficante ou traficante eventual, que pouco se dedica ao comércio espúrio e, quando o faz, realiza em pequena quantidade de drogas.

Não é o caso dos autos, à toda evidência, conforme se denota da elevadíssima quantidade de droga apreendida, além das circunstâncias fáticas advindas dos relatórios carreados em fls. 230-238, principalmente os prints de whatsapp em que o Réu aparece como fornecedor de vultosa quantidade e espécies de drogas (vide, especificamente, fls. 232 e 235). Não obstante, o Réu possui ligação estreita com o PCC, conforme se evidencia em fl. 234.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo Réu. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.^a ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpaabilidade: foi anormal, necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado, na medida em que a natureza e a variedade das drogas apreendidas denota a transcendência fática ao tipo do injusto (227 microtubos com cocaína (peso líquido - 51,9g), 84 invólucros de skunk (peso líquido - 20,8g); b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (fls. 40). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o *modus operandi* (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma de preponderância legal (quantidade e variedade de drogas) e a outra caracterizar-se por maus antecedentes por tráfico de drogas, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.346/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Ademais, não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencia à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio, conforme se denota da elevadíssima quantidade de droga apreendida, além das circunstâncias fáticas advindas dos relatórios carreados em fls. 230-238, principalmente os prints de whatsapp em que o Réu aparece como fornecedor de vultosa quantidade e espécies de drogas (vide, especificamente, fls. 232 e 235). Não obstante, o Réu possui ligação estreita com o PCC, conforme se evidencia em fl. 234. Inclusive os policiais, sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução e julgando, asseveraram que "o Réu desempenha função hierárquica importante no escalão do tráfico".

Cediço é que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA

AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Assim, estabeleço a pena final do réu em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (sendo uma de preponderância legal, qual seja, a quantidade e variedade de droga, e a outra caracterizar-se por maus antecedentes pela mesma conduta de tráfico de drogas), deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a" do Código Penal). Ademais, o regime inicial deve ser o fechado, na hipótese dos autos, a despeito da extensão da pena carcerária aplicada, porquanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, atingiria um número considerável de usuários, como acima anotado, não autoriza a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Não bastasse isso, o comprovado envolvimento do Réu com conhecida organização criminosa (PCC), impõe o equipamento prisional inicialmente fechado.

Com efeito, o Réu não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencência à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio, conforme se denota da elevadíssima quantidade de droga apreendida, além das circunstâncias fáticas advindas dos relatórios carreados em fls. 230-238, principalmente os prints de whatsapp em que o Réu aparece como fornecedor de vultosa quantidade e espécies de drogas (vide, especificamente, fls. 232 e 235).

Não obstante, o Réu possui ligação estreita com o PCC, conforme se evidencia em fl. 234. Inclusive, os policiais, sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução e julgando, asseveraram que "o Réu desempenha função hierárquica importante no escalão do tráfico".

Destarte, conforme "relatório de análise de extração de aparelho celular" (RDO 155/2022), coligido em fls. 230-238, denota-se, estreme de dúvidas, que o Réu Emilio dedicava-se à narcotraficância com habitualidade.

Ora, as vultosas quantidades de drogas comercializadas e os demais elementos extraídos da moldura fática subjacente (vide os prints de troca de mensagens em fls. 232 e as imagens de balanças contendo drogas em fls. 233, por exemplo)

demonstram a dedicação de Emilio à mercancia espúria.

Não obstante a isso, a conversa com o interlocutor nomeado "Ze Aldo" (fls. 234-235) demonstra a existência de certo vínculo com o malsinado "Primeiro Comando da Capital", eis que o Réu menciona a necessidade de autorização dos Tribunais do Crime para o comércio das drogas na Vila Esperança. Destarte, "fica evidenciado nesta conversa que o indiciado Leonardo é pertencente ao crime organizado, devido que a pessoa de 'Ze Aldo', comerciante precisa entrar em contato com Leonardo para que o problema seja levado para a 'Disciplina'" (fl. 234).

O Réu, inclusive, segundo a palavra dos policiais, tentou se evadir, quando abordado. Necessitaram bloquear o automóvel por três vezes.

Pelo mesmo motivo, e ainda em virtude do quantum da pena corporal aplicada, o réu não faz jus à substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 06/07) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais.

O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério

quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, de pois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu EMÍLIO LEONARDO PASSOS PEREIRA, vulgo "Leo", qualificado a fls. 14, à pena 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

Em virtude do teor da presente decisão, malgrado o regime de cumprimento de pena fixado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP, notadamente em face do julgamento meritório, no c. STJ, do HC nº 736599/SP (2022/0111963-9), impetrado pelo Réu (fls. 206-210).

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido (fls. 06/07) em decorrência de tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito" (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intím-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);

c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.

g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA